- **تقسيم الشرط باعتبار جهة اشتراطه:**

ينقسم الشرط من حيث جهة اشتراطه إلى قسمين:

١ - الشرط الشرعي:

وهو ما اشترطه الشارع للأحكام والتصرفات، مثل الشروط التي وردت في العبادات والمعاملات وإقامة الحدود، منها قوله ﷺ: "إنما البيع عن تراض"[(١)]، ويوجد نماذج لبعض الشروط الشرعية في النصوص القانونية، منها:

- المادة الثامنة عشرة من نظام الأحوال الشخصية: "يشترط في الولي - في الزواج - أن يكون ذكراً، بالغاً عاقلاً، موافقاً للمرأة في الدين، فإن فقد شرط، زوَّج الولي الذي يليه".
- المادة الثالثة عشرة من نظام الأحوال الشخصية: "يشترط لصحة عقد الزواج ما يأتي: ١ - تعيين الزوجين ٢ - رضا الزوجين".
- المادة (١٧٦) من نظام الأحوال الشخصية: "يشترط في الموصي أن يكون بالغاً عاقلاً".

٢ - الشرط الجَعْلي:

وهو ما اشترطه المكلف، كما لو اشترطت المرأة تقديم معجل المهر كله، وكما لو اشترط المشتري نقل المبيع أو استلامه في مكان معين.

ولا بد أن يكون الشرط الجعلي موافقًا لحكم الشرع، ومتفقًا مع مقتضى العقد أو التصرف، فإن كان منافياً له بطل التصرف، كما لو اشترط الرجل في عقد الزواج عدم النفقة أو اشترط البائع تقييد ملكية المشتري، ولذا تتفاوت درجات الشرط الجعلي.

---

(١) رواه ابن ماجه برقم (٢١٨٥)، وصححه الألباني. ينظر: إرواء الغليل (٥/١٢٥).

Scanned with CamScanner

فإما أن يكون مكملًا لحكمة الشرع ومتفقًا مع مقتضى العقد، ومحققًا للغاية منه كاشتراط الكفالة أو الرهن في الدَّيْن المؤجل، وهذا القسم متفق على صحته.

وإما أن يكون الشرط الجعلي مخالفاً لمقتضى العقد ومتعارضاً معه، وغير ملائم لمقصود المشروط فيه ولا مكملاً لحكمته، كأن يشترط الزوج عدم الإنفاق على زوجته، أو أن يشترط البائع عدم انتفاع المشتري بالعين، وهذا القسم متفق على بطلانه وإلغائه.

جاء في الفقرة (٢) من المادة التاسعة والعشرون من نظام الأحوال الشخصية:

"يصح عقد الزواج ويبطل الشرط إذا كان منافياً لمقتضى العقد".

وإما أن يكون شرطاً زائداً على مقتضى العقد، وهو الذي يقترن فيزيد من التزامات أحد الطرفين، أو يقوي هذه الالتزامات، وحكم هذا النوع مختلف فيه بين المذاهب اختلافاً واسعاً، والحنابلة على جوازه والتوسع فيه.

٣ - المانع:

وهو: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم،

ومثاله: القتل، فإنه يلزم من وجود القتل منع التوارث بين القاتل والمقتول، ولكن لا يلزم من عدم القتل وجود الميراث بين الشخصين فربما لا يحصل ميراث لمانع آخر، كوجود دين على المورّث يستغرق ماله كله.

Scanned with CamScanner

- **رسم توضيحي:**

		الحكم
السبب	إذا لم يوجد	لم يوجد الحكم إذا لم تغرب الشمس< لم يجب الإفطار
	إذا وُجد	وجد الحكم إذا غربت الشمس< وجب الإفطار
المانع	إذا لم يوجد	قد يوجد الحكم وقد لا يوجد
	إذا وُجد	لم يوجد الحكم من قتل أباه< مُنع من الميراث
الشرط	إذا لم يوجد	لم يوجد الحكم إذا عُدمت الطهارة< لم تصح الصلاة
	إذا وُجد	قد يوجد الحكم وقد لا يوجد لا يلزم من الطهارة وجوب الصلاة، فقد تجب وقد لا تجب

٤ - الرابع والخامس: الصحة والفساد والبطلان[1]:

أفعال المكلفين إذا وقعت مستوفية أركانها وشروطها حكم الشارع بصحتها، وإذا لم تقع مستوفية أركانها وشروطها حكم الشارع بعدم صحتها.

ومعنى صحتها: أنها تترتب عليها آثارها الشرعية، فإذا كانت من العبادات برئت ذمة المكلف منها، كالصلاة المستوفية لأركانها وشروطها، وإن كانت من المعاملات ترتبت عليها آثارها الشرعية.

(١) ينظر: علم أصول الفقه (١/١٣٦).

Scanned with CamScanner

ومعنى بطلانها: عدم ترتب آثارها الشرعية عليها؛ إما لخلل في الشروط أو الأركان أو غيرها، فإن كانت هذه الأفعال من العبادات - كمن صلّى بلا طهارة - لم تبرأ ذمة المكلف، ولا فرق في العبادات بين الفساد والبطلان عدا الحج باتفاق الفقهاء.

أما في المعاملات فقد اُختلف في وصف العقد غير الصحيح على قولين:

- **القول الأول:** أن العقد غير الصحيح قسم واحد، وهو الفاسد أو الباطل، ولا فرق بين الفساد والبطلان في المعاملات كالعبادات، سواء كان الخلل في الركن أو في الشرط والوصف، والفساد والبطلان مترادفان، وهو قول الجمهور.

- **القول الثاني:** العقد غير الصحيح قسمان، فاسد وباطل، فإن حدث خلل في الركن فهو باطل، ولا يترتب عليه أثر، وإن حدث الخلل في الشرط أو الوصف فيكون العقد قد انعقد بأركانه وترتبت عليه بعض الآثار، ولكنه فاسد، وهو قول الحنفية.

فالباطل عند الحنفية: ما كان غير مشروع لا بأصله ولا بوصفه، أي أن الخلل فيه راجع إلى أركان العقد، أي إلى صيغة العقد أو العاقدين أو محل العقد، مثل: بيع المجنون، ونكاح المحارم.

وأما الفاسد عندهم: فهو ما كان مشروعاً بأصله (أي بأركانه) لا بوصفه، أي أن الخلل فيه راجع إلى أوصاف العقد لا إلى أركانه، فأركانه سليمة، ولكن الخلل طرأ على بعض أوصافه وشروطه، كالبيع مع جهالة الثمن، والنكاح بدون شهود.

وعلى هذا قالوا: إن بيع المجنون أو غير المميز أو بيع المعدوم باطل وأما البيع بثمن غير معلوم فهو فاسد، وإن زاوج غير المميز أو زواج إحدى المحرمات مع العلم بالحرمة باطل، وأما الزواج بغير شهود فهو فاسد، ولم يرتبوا على الباطل أثراً، ورتبوا على الفاسد المهر والعدة وأثبتوا النسب، وفي البيع الفاسد إذا رُفع سبب الفساد في المجلس بأن عيَّن الثمن أو الأجل ترتبت على العقد آثاره.

Scanned with CamScanner

- **موقف النظام السعودي:**

نظرة في واقع الأنظمة السعودية نجد أنها تميل إلى مذهب الحنفية في تقسيم العقود غير الصحيحة إلى فاسدة وباطلة، ومن أمثلة ذلك ما جاء في نظام الأحوال الشخصية في المادة الثلاثين حيث ورد ما نصه:

"**الزواج نوعان، وهما:**

١- زواج صحيح.

٢- زواج غير صحيح، ويشمل:

أ- الزواج الباطل.

ب- الزواج الفاسد"

حيث إن الزواج الباطل يكون بتخلف أحد الأركان أو عدم تعيين الزوجين أو عدم رضاهما أما الزواج الفاسد فيكون إذا تم العقد بلا شهود أو بلا إيجاب من الولي، أو حال زواج محرم أو محرمة بحج أو عمرة.

والأخذ بهذا التقسيم الثلاثي موقف حسن، حيث إن المخالفات ليست على وزان واحد، وقوة الجزاء ينبغي أن تتواءم مع درجة المخالفة، فمن المخالفات ما يكون أساسياً في صلب العقد، ومنها ما يكون فرعياً في أوصافه، فكان الأقرب ألا يكون الموقف منها واحداً، وإنما يتواءم مع درجتها.

Scanned with CamScanner

الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي[1]:

يؤخذ مما تقدم أن الحكم التكليفي يختلف عن الحكم الوضعي، والفرق بينهما يتلخص فيما يلي:

١ - أن الحكم التكليفي لا يوصف به إلا فعل المكلف، وهو البالغ العاقل، أما الحكم الوضعي فلا يختلف باختلاف الفاعل، فمن فعل ما هو سبب للضمان أُلزم به، سواء أكان بالغاً عاقلاً أم لا، فالصبي إذا أتلف شيئاً لغيره انعقد سبب الضمان.

٢ - أن الحكم التكليفي من شرطه العلم، فالجاهل به لا يثبت في حقه تكليف، والحكم الوضعي لا يشترط العلم به، فمن فعل المحرم جاهلاً بتحريمه لا يأثم بل يُعذر، ولكن من فعل سبباً من أسباب الضمان لزمه وإن لم يعلم بكونه سبباً للضمان.

٣ - أن خطاب التكليف يشترط فيه قدرة المكلف على فعل ما كلف به؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾[2]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾[3] وأما خطاب الوضع فليس من شرطه ذلك، ولهذا فإن كثيراً من الأسباب لا قدرة للمكلف على إيجادها أو منعها ولا يمنع ذلك من كونها أسباباً، مثل دخول شهر رمضان سبب لوجوب الصوم مع كون السبب المذكور ليس في مقدور المكلف منعه ولا إيجاده، وموت المورث سبب للإرث وليس هو من فعل الوارث ولا داخلاً تحت قدرته، وكذلك الشأن في الموانع تمنع الحكم وإن كانت ليست من فعل الإنسان الذي له علاقة بذلك الحكم،

---

(١) ينظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (٦٥).

(٢) سورة البقرة (الآية: ٢٨٦).

(٣) سورة الحج (الآية: ٧٨).

Scanned with CamScanner

فوجود الجمع من الإخوة يمنع الأم من إرث الثلث وليس لها مدخل فيه ولا تستطيع منعه ولا إيجاده.

٤. أن الحكم التكليفي توصف به الأفعال التي هي من كسب العبد، وما ليس من كسبه لا يكون مكلفاً به، فكل فعل يقع من غير كسب من العبد لا يقال إنه حرام عليه ويستحق عليه العقوبة، ولا يُقال إنه واجب أو مندوب في حقه فلا ينال عليه ثواباً، قال تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾[١]، وهذا لا يتعارض مع حديث: "من سنَّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً"[٢]، وذلك لأن التسبب كسب، فما وقع نتيجة لفعله فله أجره وعليه وزره.

وأما الحكم الوضعي فلا يشترط أن يكون من كسب العبد فقد يكون من كسبه ككثير من الشروط التي تشترط لصحة العبادة، وقد لا يكون من كسبه كالأسباب والشروط والموانع الخارجة عن كسبه، مثل القرابة فهي سبب للميراث، وليست من كسب الإنسان.

ونظرة في المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة ترينا عدة أمثلة من النوعين، منها:

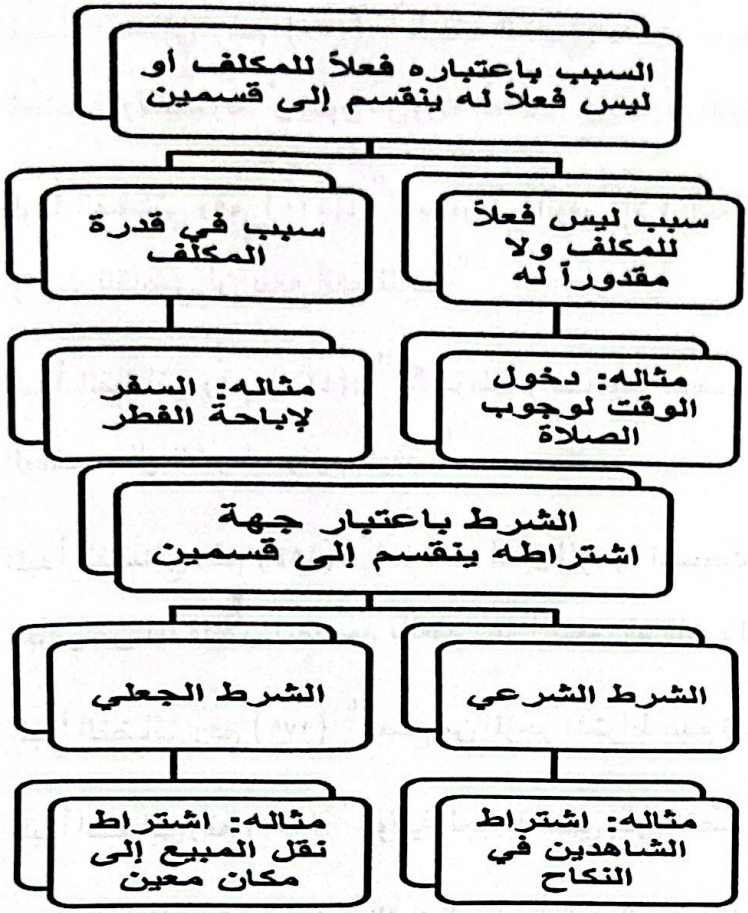
- المبدأ القضائي رقم (٧٩٨): "عدم تعجيل القصاص عند وجود قاصر، لأنه حق لعموم الورثة".
- المبدأ القضائي رقم (٤٦٩): "إذا عزل القاضي الناظر لأمر شرعي، تعيّن عليه إنهاء الأمر بتولية ناظر آخر".

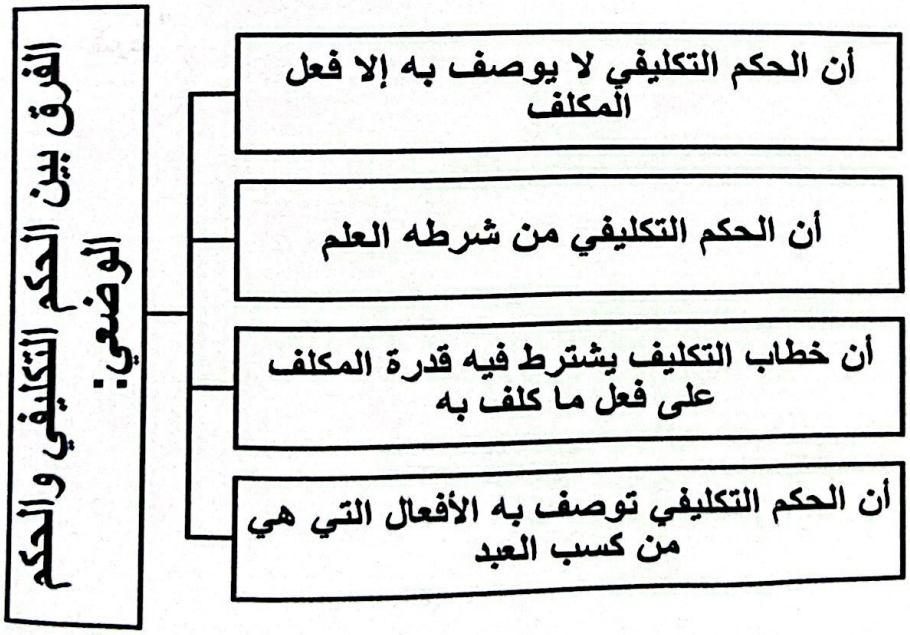
---

(١) سورة النجم (الآية: ٣٩).

(٢) رواه مسلم برقم (١٠١٧).

Scanned with CamScanner





Scanned with CamScanner

نماذج

المبحث الثالث

المحكوم عليه[1]

- **تعريفه:**

هو المكلف الذي تعلق حكم الشارع بفعله.

- **شروطه:**

يشترط في المكلف لصحة تكليفه شرعاً شرطان:

أحدهما: أن يكون قادراً على فهم دليل التكليف، بأن يكون في استطاعته أن يفهم النصوص التي يكلف بها من القرآن والسنة بنفسه أو بالواسطة، لأن من لم يستطع فهم دليل التكليف لا يمكنه أن يمتثل ما كلف به ولا يتجه قصده إليه، والقدرة على فهم أدلة التكليف إنما تتحقق بالعقل وبكون النصوص التي يكلف بها العقلاء في متناول عقولهم فهمها، لأن العقل هو أداة الفهم والإدراك، وبه تتوجه الإرادة إلى الامتثال، ولما كان العقل أمراً خفيّاً لا يُدرك بالحسّ الظاهر، ربط الشارع التكليف بأمر ظاهر يدرك بالحس هو مظنة للعقل وهو البلوغ، فمن بلغ الحلم من غير أن تظهر عليه أعراض خلل بقواه العقلية فقد توافرت فيه القدرة على أن يكلف.

وعلى هذا لا يكلف المجنون ولا الصبي؛ لعدم وجود العقل الذي هو وسيلة فهم دليل التكليف، ولا يكلف الغافل والنائم والسكران؛ لأنهم في حال الغفلة أو النوم أو السكر ليس في استطاعتهم الفهم. ولهذا قال رسول الله ﷺ: "رفع القلم عن ثلاثة:

---

(١) ينظر: علم أصول الفقه (٢٣٣)، المأمول في علم الأصول (٣٦).

Scanned with CamScanner

النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل"[1]، وقال ﷺ: "إذا رقد أحدكم عن الصلاة، أو غفل عنها، فليصلها إذا ذكرها"[2].

وأما إيجاب الزكاة والنفقة والضمان على الصبي والمجنون فليس تكليفاً لهما، وإنما هو تكليف للولي عليهما بأداء الحق المالي المستحق في مالهما، كأداء ضريبة أملاكهما.

وأما من لا يعرفون اللغة العربية ولا يستطيعون فهم أدلة التكليف الشرعية من القرآن والسنة، فهؤلاء لا يصح تكليفهم شرعاً إلا إذا تعلموا اللغة العربية واستطاعوا أن يفهموا نصوصها، أو تُرجمت أدلة التكليف الشرعية إلى لغتهم، بحيث يستطيعون أن يجدوا كتاباً دينيّاً بلغتهم يبين لهم ما يكلفهم به الإسلام، أو قامت طائفة بتعلم لغات هذه الأمم التي لا تعرف اللغة العربية ونشرت بينهم تعاليم الإسلام وأدلته التكليفية مخاطبة لهم بلغتهم، فقد أشهد الرسول ﷺ الله في خطبته يوم حجة الوداع أنه بلغ رسالته، وأمر المسلمين أن يبلغ منهم الشاهد الغائب؛ والشاهد يشمل كل من اهتدى إلى الإسلام وعرف أحكامه، والغائب يشمل كل من لم يعرف لغة القرآن ولم يستطع فهم آياته.

فأما إذا تُرك هذا الغائب على حالة لا يعرف لغة القرآن ولا يستطيع أن يفهم دلائله، ولا تُرجمت آياته إلى لغته، ولا قام أحد يعرف لغة القرآن بتعليمه ما يكلف به باللغة التي يفهمها؛ فهو شرعاً غير مكلف، لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، ولهذا قال الله تعالى في سورة إبراهيم: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾[3].

---

(١) رواه أبو داوود في السنن برقم (٤٤٠٣)، والترمذي برقم (١٤٢٣)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٤/٢).

(٢) رواه مسلم برقم (٦٨٤).

(٣) سورة إبراهيم (الآية: ٤).

Scanned with CamScanner

وثانيهما: أن يكون أهلاً لما كلف به.

الإكراه

بأن يقدر على فهم الخطاب الشرعي حال كونه مختاراً له، فالملجأ غير مكلف لكونه غير مؤهل لما كلّف به؛ إذ لا رضا عنده ولا اختيار، وكذا النائم حال نومه، والساهي حال سهوه، غير مؤهلين لفهم الخطاب، ولذلك لم يقع عليهما تكليف شرعي، إلا ما كان من باب الحكم الوضعي كما سبق.

والأهلية هي: صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، والإتيان بالتصرفات منه.

وتنقسم الأهلية إلى قسمين:

- **الأول: أهلية الوجوب:**

وهي: صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له وعليه، ومناط أهلية الوجوب هو وجود الذمة لدى الجهة المتعلق بها الحق أو الواجب، سواء أكانت تلك الجهة إنساناً أم كانت شركة، فلذلك صح تعلق الحقوق بمؤسسة، ووجبت عليها واجبات، ما دامت تلك المؤسسة مؤهلة لذلك الأمر، باعتبارها شخصاً معنوياً.

وأهلية الوجوب لا تخلو من حالتين:

أ - أهلية وجوب ناقصة، وهي: صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له فقط، وهي ثابتة للجنين في بطن أمه، وبها يكون أهلاً لاستحقاق الإرث والوصية وغلة الوقف. الهبات - الوصية

ب - أهلية وجوب كاملة، وهي: صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له وعليه، وهي تثبت للإنسان من ولادته إلى موته.

Scanned with CamScanner

نماذج

الثاني: أهلية الأداء:

وهي: صلاحية المكلف للتصرف الشرعي قولاً وفعلاً، بحيث إذا صدر منه عقد أو تصرف كان معتبراً شرعاً وترتبت عليه أحكامه، وإذا صلّى أو صام أو حج أو فعل أي واجب كان معتبراً شرعاً ومسقطاً عنه الواجب، وإذا جنى على غيره في نفس أو مال أو عرض أُخذ بجنايته وعوقب عليها بدنيّاً ومالياً، وأساس ثبوت هذه الأهلية هو التمييز بالعقل، فلا تثبت للطفل غير المميز ولا المجنون، وتنقسم إلى أهلية أداء ناقصة، وأهلية أداء كاملة.

أ - أهلية الأداء الناقصة:

وتكون في طور التمييز، وهو من سن السابعة إلى سن البلوغ، ويترتب على نقصان أهلية الأداء عند المميز ما يلي:

أولاً: في العبادات:

يثاب عليها ويؤجر وليُّه، وتكتب له حسناته دون سيئاته، وجاء حث الشريعة على أمره بالصلاة والصوم وبقية أعمال الخير، لأجل التعويد عليها.

ثانياً: في التصرفات المالية:

تنقسم تصرفات المميز المالية إلى ثلاثة أقسام:

١ - التصرفات المالية النافعة له نفعاً محضاً، كقبوله الهبة والصدقة، فتصح من غير حاجة لإجازة وليّه بالإمضاء.

٢ - التصرفات المالية الضارة ضرراً محضاً، كتبرعاته، فلا تصح.

٣ - التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر، كالبيع، فهي موقوفة على إجازة وليّه.

Scanned with CamScanner

ثالثاً: في الجنايات:

أقرت الدولة - حفظها الله - نظاماً باسم "نظام الأحداث" حيث عرَّف النظام "الحدث" في المادة الأولى منه بأنه: "كل ذكر أو أنثى أتم (السابعة) ولم يتم (الثامنة عشرة) من عمره"، وعليه فكل من أتم السابعة ولم يبلغ الثامنة عشر وقت ارتكاب الجريمة يخضع لتفاصيل النظام الذي حدد عقوبات تتناسب مع هذه المرحلة من حيث عدم اكتمال النمو العقلي والنضج وعدم بلوغ سن الرشد.

ب - أهلية الأداء الكاملة:

وهي: صلاحية الإنسان لصدور جميع الأفعال منه، والاعتداد بها شرعاً، حيث يتوجه إليه الخطاب بجميع التكاليف الشرعية من الإيمان والعبادات وغيرها من سن البلوغ، أما المسؤولية القانونية فإنها تبدأ بسن الرشد الذي حددته الدولة بالثامنة عشر حيث تصح منه جميع العقود والتصرفات الشرعية، ويترتب عليه آثارها، وهذا ينطلق من الآية الكريمة: ﴿فَإِنْ آنَسْتُم مِنْهُم رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِم أَمْوَالَهُم﴾[1] فجعل الله سبحانه دفع الأموال إليهم مشروطاً بالرشد، وهو مرحلة متقدمة على البلوغ، وقد فسر ابن عباس - رحمه الله - الرشد بأنه: (صلاح العقل وحفظ المال) [2]، بحيث يكون الإنسان بلغ مرتبة تؤهله لحفظ ماله وصيانته فيُسلَّم له، ليديرها بنفسه، ونلاحظ أن التشريع الإسلامي حدد الرشد ليكون المرحلة التي تسلم فيها أموال القاصر إليه، وترك تحديد سن الرشد لأنه يختلف باختلاف البيئات والظروف والأحوال والأزمان، وقد حددته الدولة - حفظها الله - بسن الثامنة عشر حيث رأت أن هذا السن مناسب لارتفاع الولاية عنه وتحمله المسؤولية القانونية عن تصرفاته، بحيث يتم تسليمه أمواله ليديرها بنفسه.

---

(١) سورة النساء (الآية: ٦).

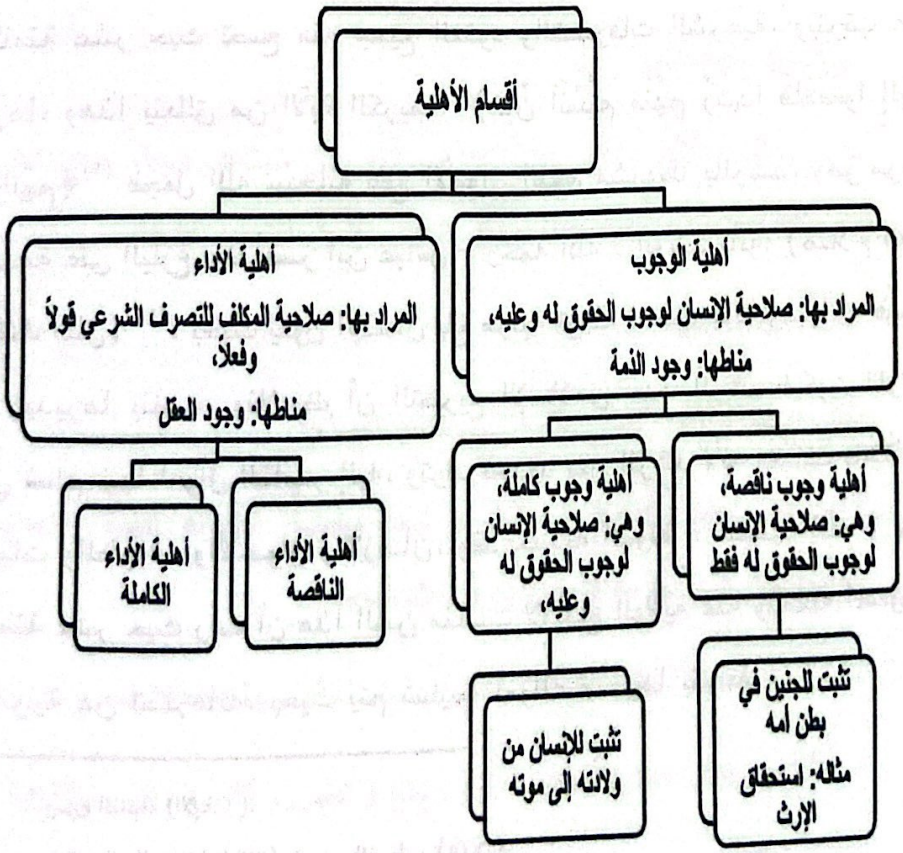
(٢) ينظر: زاد المسير (٣٨٢/١)، تفسير القرطبي (٣٧/٥).

Scanned with CamScanner

جاء في المادة (٢٢٤) مكرر من نظام المرافعات الشرعية: "تكون الولاية المالية على القاصر سناً حتى إتمامه سن (الثامنة عشرة) ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه، وللولي التقدم إلى المحكمة بطلب استمرار الولاية المالية على من أتم سن (الثامنة عشرة) عند وجود مقتضٍ لذلك".

ونصت المادة (١٣٥) في الفقرة (٢) من نظام الأحوال الشخصية على أنه: "تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانية عشر عاماً".

كما يقتضي نظام الأحوال الشخصية في المادة التاسعة منع توثيق عقد الزواج مالم يتم الزوجان الثامنة عشر عاماً، ولم يستثن إلا حالات خاصة تتحقق فيها المحكمة من حصول المصلحة بهذا الزواج.



Scanned with CamScanner

- **تدريب:**

تختلف أهلية الإنسان باختلاف أطوار حياته، بناءً على ذلك: ضع/ي في الفراغات التالية ما يناسبها باختيار أحد ما بين القوسين (لا تثبت، تثبت ناقصة، تثبت كاملة):

الطور	أهلية الوجوب	أهلية الأداء
طور الجنين في بطن أمه		
طور الطفولة (من وقت الولادة إلى سن التمييز)		
طور التمييز		
طور البلوغ		
الرشد		

- **عوارض الأهليّة**[1]

إن أهلية الأداء تساوي المسؤولية التي تقوم على العقل، وبما أن أحوال الإنسان وقدراته العقلية معرضة لطوارئ ونقص وتغيير، فإن قدرته على الفهم وصلاحيته للالتزامات تتغير، وبالتالي فإن أهلية التكليف تختلف بحسب الطوارئ، وأطلق العلماء على هذه العوامل التي تؤثر في أهلية الأداء اسم عوارض الأهلية، لأنها تمنع الأحكام التي تتعلق بأهلية الأداء من الثبوت؛ لنقص في العقل أو فقدانه.

(١) ينظر: الوجيز في أصول الفقه لمحمد الزحيلي (١/٤٩٥).

Scanned with CamScanner

- **تعريفها:**

الأمور التي تطرأ على أهلية الأداء عند الإنسان فتؤثر بها.

- **الأهلية التي تتأثر بالعوارض:**

إن الأهلية التي تتأثر بالعوارض هي أهلية الأداء فقط، وذلك لأن مناطها - كما سبق - هو التمييز بالعقل، فهي ترتبط به وجوداً وعدماً ونقصاً وزيادة، فلذلك كانت الأمور التي تطرأ عليها والتي سميناها عوارض تؤثر فقط بأهلية الأداء.

أما أهلية الوجوب فمناطها الذمة، وبالتالي تكون مع الإنسان منذ وجوده في بطن أمه حيث تكون ناقصة، ثم تستمر وتكتمل بولادته، وتبقى ملازمة له في جميع أحواله لا تفارقه إلا بالموت، ولذلك فالعوارض لا تؤثر فيها.

- **أنواع العوارض:**

أولاً: أقسام العوارض من حيث المنشأ:

تنقسم العوارض من حيث المنشأ إلى عوارض سماوية وعوارض مكتسبة:

١ - العوارض السماوية:

وهي الأوصاف التي تلحق الشخص من الله تعالى دون أن يكون للإنسان فيها اختيار، فهي خارجة عن قدرة الإنسان وكسبه، وهي:

الجنون، العته، مرض الموت، النوم، الإغماء.

٢ - العوارض المكتسبة:

وهي الأوصاف التي تلحق بالشخص، ويكون للشخص في وقوعها اختيار، وهي نوعان:

Scanned with CamScanner

أ - ما يكون من نفس الإنسان: كالجهل، والسكر، والهزل، والخطأ، والسفه.

ب - ما يكون من غيره عليه: كالإكراه.

ثانياً: أقسام العوارض من حيث تأثيرها على أهلية الأداء:

تنقسم العوارض من حيث تأثيرها على أهلية الأداء إلى ثلاثة أقسام:

- **القسم الأول: عوارض تزيل أهلية الأداء.**

وتشمل الجنون والنوم والإغماء والإكراه، فأما الجنون والنوم والإغماء فيصبح الإنسان معها عديم الأهلية تمامًا، وتنعدم عنه التكاليف، قال رسول الله ﷺ: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"[1]، والمراد رفع المؤاخذة، وهذا يستلزم رفع التكليف.

جاء في المبدأ القضائي رقم (١١٩١): "لا يقام الحدّ على المجنون حال جنونه".

وأما الإكراه فلا يخلو من حالتين:

- **الأولى:** إكراه غير ملجئ، أو ناقص، وهو يتحقق بالتهديد بما لا يفوت النفس أو بعض الأعضاء، كالضرب الذي لا يخشى منه الموت، وهذا لا تنعدم معه أهلية الأداء.
- **الثانية:** إكراه ملجئ أو كامل، وهو يتحقق بالتهديد بالقتل أو بإتلاف أحد الأعضاء.

واعتبار الرضا ومنع الإكراه مبناه الشريعة الإسلامية حيث إنها جعلت الرضا شرطاً في جميع العقود سواء العقود المالية أو عقود الأنكحة، ونصت على ذلك الأدلة الشرعية منها:

---

(١) رواه ابن ماجه برقم (٢٠٤٥)، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (٢/١٧٧١).

Scanned with CamScanner

١ - قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾[١].

٢ - قوله ﷺ: (إنما البيع عن تراض) [٢].

٣ - قوله ﷺ: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن)، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: (أن تسكت) [٣].

كما اعتبر نظام الأحوال الشخصية في مادته (٣٢) الفقرة (١) الزواج باطلاً إذا تم بدون رضا الزوجين.

وفي مادته الثمانون اعتبر طلاق المجنون والمكره والسكران غير واقع؛ لعدم الأهلية.

وورد في المبدأ القضائي رقم (٢٢٨٧) في باب الإقرار: "إذا ثبت أن الاعتراف حصل عن طريق الإكراه، فلا يُبنى عليه حكم".

وجاء في المبدأ القضائي رقم (٢٣١٦) في باب الإقرار: "الإكراه المؤثر في الإقرار، هو الإكراه الملجئ دون ما عداه".

- القسم الثاني: عوارض تنقص أهلية الأداء.

كالعته الخفيف وهو الذي يكون معه إدراك وتمييز، ولكن ليس كالعقلاء، فيكون المعتوه البالغ هنا كالصبي المميز في الأحكام، فتثبت له أهلية أداء ناقصة، فلا تجب عليه العبادات، ولكن يصح منه أداؤها، ولا تثبت في حقه عقوبات كامل الأهلية، وتجب عليه حقوق العباد المالية ويؤديها عنه وليّه كضمان المتلفات.

وحكم تصرفاته حكم تصرفات الصبي المميز - وقد سبق ذكرها -.

---

(١) سورة النساء (الآية: ٢٩).

(٢) رواه ابن ماجه برقم (٢١٨٥)، وصححه الألباني. ينظر: إرواء الغليل (٥/١٢٥).

(٣) رواه البخاري برقم (٥١٣٦)، ومسلم برقم (١٤١٩).

Scanned with CamScanner

- **القسم الثالث: عوارض تؤثر في تغيّر بعض الأحكام لمصالح معينة، ومنها:**

أ - السَّفه والغفلة:

فكل من السفيه وذي الغفلة البالغ العاقل له أهلية أداء كاملة، ولكن محافظة على مال كل منهما من الضياع، ومنعاً من أن يكون كل منهما عالة على غيره، حُجِر عليهما تصرفاتهما المالية فقط، فيكون حكم معاملاتهما المالية حكم معاملات الصبي المميز، لا لفقد الأهلية أو نقصها، ولكن محافظة على أموالهما.

ب - وكذلك المدين - المفلس - البالغ العاقل له أهلية أداء كاملة:

ولكن محافظة من الشرع على حقوق دائنيه حُجر عليه من التصرف في ماله بما يضر بحقوق الدائنين كالتبرعات، وتصح تصرفاته الأخرى إذا أجازها الدائنون، وهذا عند الجمهور، بخلاف أبي حنيفة الذي يرى أنه لا تأثير لواحد من الأمور الثلاثة في أهلية الإنسان، والمصالح التي تترتب على الحجر لا توازن الضرر الذي يلحق بالإنسان من الحجر عليه واعتباره غير أهل، فلذلك منع من الحجر على أيّ منهم.

ج - وأما المريض مرض الموت:

فإنه يحجر عليه في حدود ثلثي ماله محافظة على حقوق الورثة الذين تعلق حقهم بهذا المال، وهذا الحجر ليس لنقص أهليته أو انعدامها، ولذلك تصح تصرفاته كيفما كان في حدود الثلث كما ينفذ تصرفه في الكل إذا أجاز الورثة.

- **تدريب:** تدريب عليه

بين يديك مجموعة أمثلة، آمل تصنيفها وفق الجدول أدناه:

النائم، المغمى عليه، المعتوه، الناسي، الجنين، فتاة عمرها (٣٠) سنة، الهازل، السفيه، السكران، المكره بحق، المكره بغير حق، طفل عمره ٣ سنوات، طفل عمره ٩ سنوات، المريض، الناسي، المرأة الحائض، الجاهل.

Scanned with CamScanner

المبحث الرابع

المحكوم فيه[1]

وهو: فعل المكلف الذي تعلق به الحكم الشرعي، ويسميه بعض الأصوليين بالمحكوم به.

فمثلاً: قول الله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾[2] هو خطاب شرعي فيه حكمان شرعيان:

- **الأول**: حكم وضعي، وهو جعل الزوال سبباً لوجوب صلاة الظهر.
- **الثاني**: حكم تكليفي، وهو إيجاب صلاة الظهر على المكلف، فهذا هو المحكوم به.

لذلك، نرى الأصوليين شرطوا في المحكوم فيه ليصح التكليف به ثلاثة شروط:

الأول: أن يكون معلوماً للمكلف علماً تاماً حتى يستطيع المكلف القيام به كما طلب منه:

وعلى هذا فنصوص القرآن المجملة؛ أي التي لم يبين المراد منها، لا يصح تكليف المكلف بها إلا بعد أن يلحق بها بيان الرسول عليه الصلاة والسلام.

ففي قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ الصَّلَاةَ﴾[3] لم يبين النص القرآني أركان الصلاة وشروطها وكيفية أدائها، ولذلك بين الرسول ﷺ هذا المجمل وقال: "صلوا كما

---

(١) ينظر: علم أصول الفقه (٢٣٣)، المأمول في علم الأصول (٥٥).

(٢) سورة الإسراء (الآية: ٧٨).

(٣) سورة البقرة (الآية: ٤٣).

Scanned with CamScanner

رأيتموني أصلي"[1]، إذ كيف يكلف بالصلاة من لا يعرف أركانها وشروطها وكيفية أدائها؟

وكذلك الحج والصوم والزكاة وكل فعل تعلق به خطاب من الشارع مجمل لا يعلم مراد الشارع به، لا يصح التكليف به ولا مطالبة المكلفين بامتثاله إلا بعد بيانه، ولهذا أعطى الله ورسوله ﷺ سلطة التبيين بقوله: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾[2]، وبيّن الرسول عليه الصلاة والسلام بسننه القولية والفعلية ما أُجمِل في القرآن، واتفق العلماء على أنه لا يسوغ تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه.

ويلاحظ أن المراد بعلم المكلف بما كلف به إمكان علمه به، لا علمه به فعلًا، فمتى بلغ الإنسان عاقلًا قادرًا على أن يعرف الأحكام الشرعية بنفسه أو بسؤال أهل الذكر عنها، اعتُبر عالماً بما كُلّف به، ونفذت عليه الأحكام وألزم بآثارها ولا يقبل منه الاعتذار بجهلها، ولهذا قال الفقهاء: لا يقبل في دار الإسلام عذر الجهل بالحكم الشرعي، لأنه لو شُرط لصحة التكليف علم المكلف فعلاً بما كلف به ما استقام التكليف، واتسع المجال للاعتذار بجهل الأحكام.

وعلى هذا جرى القانون، فالناس يعتبرون عالمين بالقانون بتيسير إمكان علمهم به، وذلك بنشره بالطريق النظامي بعد إصداره، ولذلك لا يعدّ الجهل بالقانون عذراً، فبمجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية (أم القرى) ومضي المدة اللازمة لسريانه تقوم قرينة على الناس كافة بعلمهم بالقانون، فلا يقبل من أحد أن يدعي جهله به، فالعلم بالقانون مفترض في حق الكافة بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، وافتراض العلم بالقانون لدى كافة الناس يحقق مبدأ المساواة بينهم أمام القانون، فإذا أصدرت الدولة أي تشريع فلا يجوز للمخاطب بقواعده

(١) رواه البخاري برقم (٦٣١).

(٢) سورة النحل (الآية: ٤٤).

Scanned with CamScanner

الدفع بالجهل به أو عدم العلم به، فطالما الدولة تصدر أوامرها ونواهيها بواسطة قوانينها وأنظمتها ولوائحها فالمفروض أن تكون معلومة للكافة، ولذلك تعدّ قاعدة (عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون) من الأهمية بمكان، لأنها لازمة لاستقرار المعاملات وتطبيق القانون على أساس من العدل والمساواة بين المواطنين.

الثاني: أن يكون التكليف به صادر ممن له سلطان التكليف:

وممن يجب على المكلف اتباع أحكامه لأنه بهذا العلم تتجه إرادته إلى امتثاله، وهذا هو السبب في أن أول بحث في أي دليل شرعي هو حجيته على المكلفين، أي أن الأحكام التي يدل عليها أحكام واجب على المكلفين تنفيذها، وهو السبب أيضاً في أن كل قانون يتوج بالديباجة الخاصة التي تدل على أن الحاكم أصدر القانون بناء على عرض مجلس الوزراء برئاسة الملك - حفظه الله -، ليعلم المكلفون أن القانون صادر ممن لهم سلطة سنّ الأنظمة، وممن يجب عليهم امتثال تكاليفهم؛ فيتجهوا للتنفيذ.

الثالث: أن يكون الفعل المكلف به ممكنًا:

أو أن يكون في قدرة المكلف أن يفعله أو أن يكف عنه، فلا يصح التكليف بالمستحيل؛ لأن المقصود من التكليف هو الامتثال، وهو متعذر في المستحيل، فيكون التكليف به أشبه بالعبث.

- أقسام المحكوم فيه:

قسّم جمع من الأصوليين فعل المكلف الذي يتعلق به خطاب الله إلى أربعة أقسام:

الأول: ما هو حق خالص لله، وهو ما يتعلق بحق النفع العام، كالعبادات والعقوبات والكفارات.

وحكمه: أنه لا يصح لأحد التنازل عنه أو التهاون في إقامته.

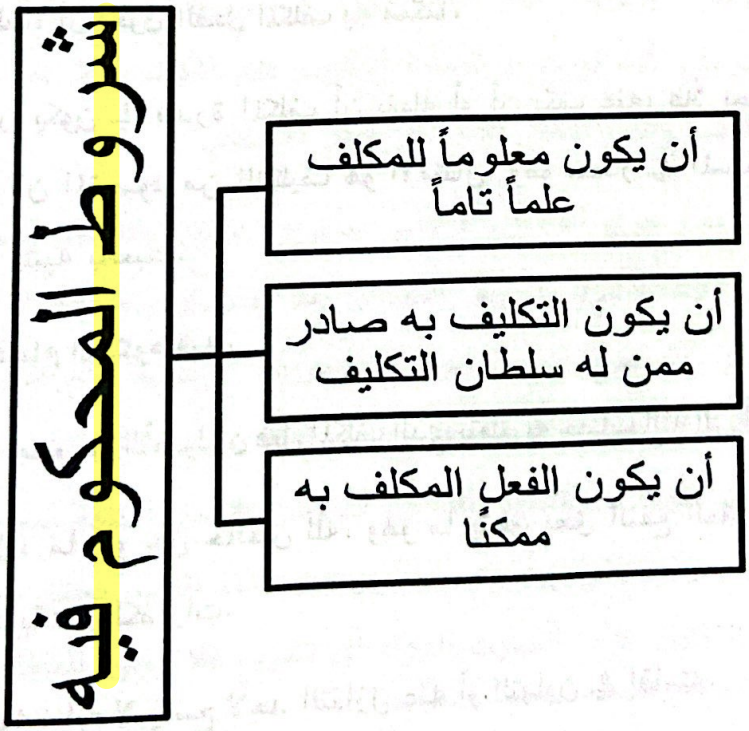
Scanned with CamScanner

الثاني: ما هو حق خالص للعبد، وهو ما يتعلق بمصلحة العبد الخاصة، كأموال الناس الخاصة. الدين

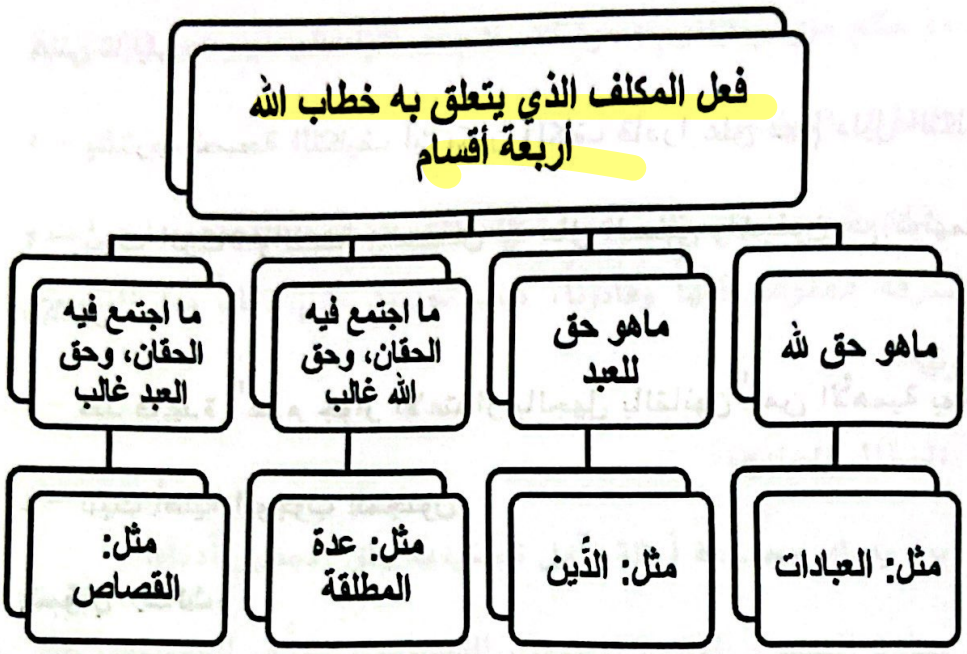
وحكمه: صحة التنازل عنه من قبل صاحب الحق.

الثالث: ما اجتمع فيه الحقان، وحق الله فيه غالب، ومثاله: عدة المطلقة، إذ إن فيها حق لله وهو الامتثال لأمره، وصيانة الأنساب، وفيها حق العبد، ويتمثل في المحافظة على نسب أولاده، لكن حق الله غالب، حيث إن حفظ النسب وصيانته يمثل نفعاً عاماً للمجتمع، فلا يصح فيه التنازل.

الرابع: ما اجتمع فيه الحقان، وحق العبد فيه غالب، وذلك كالقصاص، فإنه حق لله باعتبار إشاعة الأمن وصيانة الدماء، وهو حق للعبد باعتبار شفاء صدور أولياء المقتول، وحق العبد هنا غالب، فلذلك يصح للولي التنازل عن القصاص إلى الدية، ويمكنه كذلك العفو عن القاتل.



Scanned with CamScanner



- **أسئلة وتطبيقات**

السؤال الأول:

ضعي المصطلح المناسب للتعريفات التالية:

المصطلح	التعريف
	هو المكلف الذي تعلق حكم الشارع بفعله
	صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له فقط
	صلاحية المكلف للتصرف الشرعي قولاً وفعلاً
	هي الأوصاف التي تلحق بالشخص، ويكون للشخص في وقوعها اختيار
	الأمور التي تطرأ على أهلية الأداء عند الإنسان فتؤثر بها

Scanned with CamScanner

السؤال الثاني:

علل لما يلي:

١ - يشترط لصحة التكليف أن يكون المكلف قادراً على فهم دليل التكليف.

٢ - تجب الزكاة والنفقة والضمان في مال الصبي والمجنون مع كونهما غير مكلفين.

٣ - تعد قاعدة "عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون" من الأهمية بمكان.

٤ - تثبت أهلية الوجوب للمجنون.

السؤال الثالث:

ضع/ي علامة (صح) أو (خطأ) أمام كل عبارة بما يناسبها:

١ - مناط أهلية الوجوب هو التمييز بالعقل.

٢ - تثبت أهلية الوجوب للجنين في بطن أمه.

٣ - تصح الهبة والصدقة من الصبي المميز من غير إذن وليّه.

٤ - تم تحديد بلوغ الرشد بسن (٢١) عاماً.

٥ - لا يعد الجهل بالقانون عذراً.

السؤال الرابع:

دلل/ي لما يلي:

١ - عدم تكليف الصبي والمجنون.

٢ - اشتراط الرضا في العقود.

Scanned with CamScanner

السؤال الخامس:

ما حكم من لم تبلغهم دعوة الإسلام، وماتوا على غير دين الإسلام؟

السؤال السادس:

قام شخص بارتكاب جريمة السرقة، ولما تم القبض عليه اعتذر بجهله بأن السرقة ممنوعة فقهاً وقانوناً، كيف تجيبين على ذلك من الناحية الفقهية والقانونية؟

السؤال السابع:

بين يديك مجموعة أمثلة، آمل تصنيفها وفق الجدول أدناه:

صلاة العصر، الهاتف المحمول، القصاص، العدَّة، الحاسوب، حد القذف، كفارة اليمين، حد شرب الخمر، الصلاة، الدَّين، زكاة الفطر، الدية.

حق خالص لله	حق خالص للعبد
ما اجتمع فيه الحقان، وحق الله فيه غالب	ما اجتمع فيه الحقان، وحق العبد فيه غالب

Scanned with CamScanner

الفصل الثاني
مصادر التشريع

ويتضمن ما يلي:

- **مقدمة في الأدلة.**
- **المبحث الأول:** الأدلة المتفق عليها، ويتضمن:
- **المطلب الأول:** القرآن الكريم.
- **المطلب الثاني:** السنة النبوية.
- **المطلب الثالث:** الإجماع.
- **المطلب الرابع:** القياس.
- **المبحث الثاني:** الأدلة المختلف فيها، ويتضمن:
- **المطلب الأول:** الاستحسان.
- **المطلب الثاني:** المصلحة المرسلة.
- **المطلب الثالث:** العرف.
- **المطلب الرابع:** الاستصحاب.

Scanned with CamScanner

- **المطلب الخامس:** سد الذرائع.
- **المطلب السادس:** قول الصحابي.
- **المطلب السابع:** شرع من قبلنا.

Scanned with CamScanner

المبحث الأول

الأدلة المتفق عليها

- **تمهيد**[1]

الأحكام الشرعية إنما تعرف بالأدلة التي أقامها الشارع لترشد المكلفين، وتدلهم عليها، وتسمى هذه الأدلة: بأصول الأحكام، أو المصادر الشرعية للأحكام، أو أدلة الأحكام، فهي أسماء مترادفة، والمعنى واحد.

والدليل في اللغة: ما فيه دلالة وإرشاد إلى أي أمر من الأمور.

وفي اصطلاح الأصوليين: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، والمطلوب الخبري هو: الحكم الشرعي.

- **تقسيمات الأدلة:**

تنقسم هذه المصادر عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة، منها:

أ - من حيث أصلها، وتنقسم إلى قسمين:

١ - مصادر نقلية، كالكتاب والسنة والإجماع والعرف وشرع من قبلنا ومذهب الصحابي، وهي التي لا دخل للمجتهد فيها، وتوجد قبل المجتهد.

٢ - مصادر عقلية، وهي التي يظهر في تكوينها ووجودها أثر المجتهد، وهي القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع، وهذان القسمان

(١) ينظر: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (١/١٣١).

Scanned with CamScanner

متكاملان؛ لأن الاستدلال بالدليل النقلي لا بد فيه بذل الجهد والتدبر والنظر، والاستدلال بالمعقول لا بد أن يكون معتمدًا على النقل، حيث إن مصادر الشريعة لا تنافي قضايا العقول.

ب - من حيث الاتفاق عليها، وتنقسم إلى قسمين:

١ - مصادر متفق عليها، وهي أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس.

٢ - مصادر مختلف فيها، وهي: الاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة والعرف وشرع من قبلنا ومذهب الصحابي وسد الذرائع، وتسمى المصادر الأولى: أصلية، والثانية: مصادر تبعية؛ لأنها ترجع إلى الأولى.

وهذا التقسيم الأخير هو أهم تقسيم للمصادر، وستتم دراستها بناء عليه في المباحث الآتية.

Scanned with CamScanner